

1500558-70.2022.8.26.0536

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Silvana Amneris Rôlo Pereira Borges

Comarca: Santos

Foro: Foro de Santos

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/12/2022

... o Supremo Tribunal Federal:

"HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA NÃO CONFIGURADA. CONFISSÃO DE FATO DIVERSO DO DA CONDENAÇÃO. PRISÃO EM FLAGRANTE. IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DO ART. 65, III, D, DO CÓDIGO PENAL. INVIABILIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO NA VIA DO HABEAS CORPUS PARA AFASTAR O QUE DECIDO NA AÇÃO PENAL. ORDEM ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santos

Foro de Santos

6ª Vara Criminal

Praça José Bonifácio, s/n, Santos - SP - cep 11013-910

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500558-70.2022.8.26.0536 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500558-70.2022.8.26.0536 - Controle n.º 138/22

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GABRIEL OLIVEIRA MENDES RIBEIRO DE BARROS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Silvana Amneris Rôlo Pereira Borges

Vistos.

GABRIEL OLIVEIRA MENDES RIBEIRO DE BARROS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas sanções previstas no artigo 157, caput, e artigo 157, caput, c.c. o artigo 14, inciso II, todos do Código Penal, em concurso material, porque no dia 12 de fevereiro de 2022, por volta das 8h37min, na Avenida Siqueira Campos n.º 536, no Boqueirão, nesta Comarca, subtraiu, para si, mediante grave ameaça, a quantia de R\$ 160,05 (cento e sessenta reais e cinco centavos), pertencentes à farmácia Drogasil, representada por Gabriel Leonardo Camilo Rodrigues.

Consta, também, que na mesma data, por volta das 15h55min, na Avenida Rangel Pestana, altura do numeral 126, na Vila Mathias, nesta Comarca, GABRIEL OLIVEIRA MENDES RIBEIRO DE BARROS, mediante violência e grave ameaça, tentou subtrair, para si, a quantia de R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais), pertencentes a Agnaldo Pereira Costa.

Diz a denúncia que, por volta das 8h37min, o acusado entrou na farmácia Drogasil e anunciou o assalto ao atendente Gabriel Leonardo. Em seguida, o acusado ordenou que fosse levado até o caixa registrador. O atendente Gabriel Leonardo assim procedeu.

Ato contínuo, o réu pegou para si a quantia de R\$ 160,05 (cento e sessenta reais e cinco centavos) do caixa e fugiu do local.

Por volta das 15h55min do mesmo dia, no ponto de táxi existente próximo ao Hospital Ana Costa, o réu entrou em um táxi e pediu corrida para desembarque no Jabaquara, em local onde funciona um ponto de venda de drogas. Imediatamente, o taxista Agnaldo Pereira Costa rejeitou ir ao local solicitado, mas depois aceitou realizar o desembarque na Arena Santos. No exato momento em que o táxi estacionou, na Av. Rangel Pestana, o réu desferiu um golpe (conhecido como "gravata") no ofendido Agnaldo e exigiu que a vítima entregasse o dinheiro existente (no caso a quantia de R\$ 150,00 – cento e cinquenta reais) e o veículo automotor. Agnaldo entrou em luta corporal com o réu a fim de impedi-lo a subtrair o veículo. Durante a luta corporal, o réu chutou a face do ofendido Agnaldo. Com o auxílio de populares, o acusado foi detido e a Polícia Militar acionada.

Diz, por fim, a petição inicial que a vítima Gabriel Leonardo foi contactada para fins do reconhecimento pessoal e identificou o réu como o autor do roubo ocorrido na manhã daquele mesmo dia. O dinheiro roubado da farmácia não foi recuperado (pp. 88/90).

Recebida a denúncia (pp. 93/97), foi o réu citado pessoalmente (p. 195). O Defensor ofereceu a resposta de pp. 116/124, prosseguindo-se na persecução penal, uma vez que ausente causa de absolvição sumária (pp. 138/141).

Instaurado incidente de verificação de dependência toxicológica a pedido da Defesa (pp. 139/140), essa acabou desistindo de sua realização, o que foi acolhido pelo juízo (autos n.º 0002449-25.2022.8.26.0562, em apenso).

Na instrução foram ouvidas duas vítimas e duas testemunhas, procedendo-se, na sequência, ao interrogatório (pp. 226/227).

Em alegações finais, por memorial, o Ministério Público requereu a procedência da ação penal, entendendo provados os fatos narrados na inicial. No tocante à tentativa de roubo praticada contra o taxista, pretendeu a fixação da pena-base acima do mínimo legal, em razão das consequências desfavoráveis do crime, pois a vítima se feriu em razão da agressão física e perdeu o restante do dia de trabalho. Ademais, pleiteou o reconhecimento da agravante representada pela dissimulação ou outro recurso que dificultou a defesa da vítima, prevista no artigo 61, inciso II, alínea "c", do Código Penal, uma vez que o réu fingiu ser passageiro legítimo e, sem que a vítima pudesse suspeitar, atacou-a pelas costas, com uma "gravata", enquanto estava acomodada no banco do motorista. Presente a causa de diminuição da pena pela tentativa, requereu a aplicação de fração intermediária. Relativamente ao roubo consumado contra a drogaria, apenas observou que o acusado não possui antecedentes criminais. Por fim, requereu a fixação de regime inicial semiaberto e salientou a impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por se tratar de crimes cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa (pp. 294/303).

A Defesa, por sua vez, relativamente ao roubo praticado contra a drogaria, pleiteou a absolvição nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, alegando que o reconhecimento efetuado na delegacia não seguiu o procedimento previsto no artigo 226 do Código de Processo Penal, ao passo que, na fase judicial, o atendente da farmácia não reconheceu o réu. No tocante à tentativa de roubo cometida contra o taxista, pretendeu a absolvição com fulcro no artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal, uma vez que o acusado alegou que se desentendeu com o ofendido, negando a tentativa de subtração. Ressaltou que não houve prejuízo patrimonial para a vítima. Subsidiariamente, requereu a fixação da pena no mínimo legal, o reconhecimento da atenuante da confissão e da figura do crime tentado, a aplicação de regime inicial aberto, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a revogação da prisão cautelar, concedendo ao acusado o direito de recorrer em liberdade (pp. 304/310).

É o relatório.

Fundamento e decido.

O pedido inicial é procedente em parte.

A autoria dos fatos delituosos relativamente à tentativa de roubo praticada contra o ofendido que é taxista é certa, não sendo possível declarar a absolvição.

Melhor sorte socorre o acusado quanto ao roubo consumado, praticado contra o estabelecimento comercial denominado Drogasil, uma vez que é caso de absolvição, pois a prova aqui reunida não é suficiente e nem segura para a condenação. Ao ser preso em flagrante delito, o réu manteve-se calado, deixando de esclarecer as razões e circunstâncias que ensejaram sua prisão (p. 5).

Em juízo, ao ser interrogado, informou que nunca foi preso ou processado anteriormente. Disse que não conhece o funcionário da drogaria, recorda-se do taxista e nada tem a alegar contra ele. Conheceu os policiais militares ouvidos na audiência na data de sua prisão. Afirmou que nunca esteve na farmácia mencionada na denúncia. Contou que estava sob efeito de droga e pediu a corrida de táxi para ser levado até uma "biqueira" na subida do morro do Jabaquara. Ao se aproximarem da Avenida Rangel Pestana, o taxista parou o automóvel e falou que não o levaria até o local acordado. Respondeu que não pagaria a corrida se não fosse levado até o destino final. Em seguida, pôs a mão na porta detrás do carro e o taxista tentou segurá-lo com os braços, momento em que entrou em luta corporal com ele, agredindo-o. Quando saiu do carro, o taxista gritou "pega ladrão!" e ficou com medo de ser linchado. Revelou que nunca teve passagem criminal, estava trabalhando registrado e não precisava roubar. Todavia, é dependente químico e já ficou internado para tratamento do vício. Informou que na delegacia não foi colocado ao lado de outras pessoas para ser submetido a reconhecimento. Permaneceu todo o tempo sozinho na delegacia e foi colocado em uma sala, na qual mandaram que olhasse para frente. Não soube como foi identificado pelo roubo da farmácia. Declarou que, por diversas vezes, contratou corridas de táxi para ser levado até um ponto de venda de drogas. Reside no Canal 2, próximo à Rua Ministro Xavier de Toledo. Embarcou no táxi na Avenida Ana Costa, perto de sua casa. Referiu que, naquela data, por volta de 16h, estava em sua residência. Saiu para fazer uso de droga e acabou querendo adquirir mais entorpecente, de maneira que entrou no táxi e pediu a corrida para ir até o sopé do morro. Trazia quarenta reais em seu bolso para pagar a corrida de táxi e comprar a droga. Acredita que a corrida de táxi custaria, no mínimo, quinze reais. Um pino de cocaína pode ser adquirido por cinco reais. É usuário de cocaína há quatorze anos e já esteve internado cinco vezes para tratamento da dependência química, em clínicas em Santa Catarina e no Guarujá. Foi internado pela primeira vez aos dezoito anos. Informou residir com seus pais e esposa em casa alugada. Fazia um mês que trabalhava registrado na empresa MGM Construtora, exercendo as funções de servente de obras. Não possui filhos e todos que moram em sua casa trabalham. Concluiu o ensino médio. Questionado sobre a fotografia que aparece as pp. 23 e 28 dos autos, disse que corresponde a aparência física que possuía à época que trabalhava na empresa MGM. Não se recorda se estava com barba na data de sua prisão, mas seu corte de cabelo era bem semelhante àquele retratado nas fotografias. Foi preso em um sábado e "estava de atestado médico" válido por sete dias, pois uma semana antes fora levado ao hospital após passar mal devido ao consumo abusivo de drogas. Esclareceu que, por ocasião de sua prisão, estava com um maço de cigarro e quarenta reais em dinheiro (gravação audiovisual, pp. 226/227).

Gabriel Leonardo Camilo Rodrigues, funcionário da farmácia, declarou que a loja em que trabalha é frequentemente vítima de roubos. Em audiência virtual, ao observar o acusado – que segurava a placa número 1 – e os outros dois detentos colocados para reconhecimento – e que seguravam as placas número 2 e 3 –, apontou como autor do fato o rapaz que segurava a placa número 2. Contou que o assaltante entrou na farmácia e pediu o auxílio de um funcionário, como se precisasse de atendimento para comprar algum medicamento. Em seguida, o criminoso o levou até o caixa para retirar o dinheiro. Tão logo conseguiu pegar o dinheiro de um dos caixas, o assaltante saiu da loja correndo. Estimou que o agente subtraiu cerca de cento e oitenta reais. Esclareceu que o assaltante fez menção de estar armado, mas não mostrou arma de fogo. Não o conhecia. Foi chamado na delegacia naquele mesmo dia e lá reconheceu o indivíduo que lhe foi mostrado. Observou o rapaz que estava no interior de uma sala e não teve qualquer dúvida em apontá-lo como autor da subtração. Afirmou que o rapaz que reconheceu na delegacia se assemelha ao detento que segurava a placa número 2, pois ambos possuem tatuagens. Informou que o dinheiro subtraído da drogaria não foi recuperado. Não se recorda das vestimentas

do assaltante ou se ele usava máscara facial. Não sabe se a drogaria possuía gravação de imagens da ação criminosa (gravação audiovisual, pp. 226/227). Agnaldo Pereira Costa, em audiência virtual, ao observar o réu – que segurava a placa número 1 – e os outros dois detentos colocados para reconhecimento – que seguravam as placas número 2 e 3 –, apontou o acusado como autor do crime. Narrou que o réu ingressou em seu veículo na altura do Hospital Ana Costa e pediu corrida de táxi até a Arena Santos, alegando que havia um evento muay thai neste local. O acusado tentou agredi-lo ao descer do carro, segurando-o pelo pescoço, e exigiu a entrega de dinheiro. Todavia, puxou o seu banco para trás e reagiu, não permitindo que o acusado subtraísse algum bem. Esclareceu que, de imediato, avisou ao réu que não fazia corridas até um ponto de drogas no morro do Jabaquara e ele respondeu que seu destino final era próximo à faculdade. Negou que as agressões tenham sido motivadas por desavença sobre o destino final da corrida de táxi, pois na hora que parou o veículo, o acusado falou que ficaria naquele local. Tão logo encerrou a corrida e informou o valor a ser pago, o acusado já agiu de forma alterada e agitada, iniciando as agressões físicas e exigindo a entrega de dinheiro. Ao perceber que o acusado não estava armado, puxou seu banco para trás e travou luta corporal com o réu, ocasião em que ele acertou um isqueiro em seu rosto, cortando-o na altura dos olhos. Informou que pessoas se aproximaram e a Polícia Militar foi rapidamente acionada, chegando ao local em seguida. Revelou que nada foi subtraído, mas o réu não pagou a corrida de táxi. Ficou sem trabalhar o restante do dia, pois estava lesionado. Não realizou exame de corpo de delito porque teria que se locomover até a cidade de Praia Grande para ir ao IML. Esclareceu que o acusado sentou-se no banco de trás, seguindo viagem sozinho como passageiro. Disse que ficou muito nervoso com a agressão pois seu rosto sangrou e precisou levar três pontos no hospital (gravação audiovisual, pp. 226/227).

Victor Hugo Caldeira Duarte, policial militar, contou que foram acionados via COPOM para atenderem uma ocorrência de roubo em andamento na Avenida Rangel Pestana. No local, verificaram que o acusado havia acabado de assaltar um taxista. Encontraram o taxista no chão com o rosto sangrando e populares apontaram o acusado, que estava tentando fugir. Conseguiram deter o réu um pouco mais à frente do local onde o táxi estava parado e os policiais da viatura de apoio reconheceram o acusado como autor do roubo ocorrido numa farmácia naquela manhã. Na delegacia, o responsável pela drogaria reconheceu o acusado sem qualquer dúvida. Acompanhou este reconhecimento. Esclareceu que o taxista havia narrado que o acusado ingressou no táxi e pediu corrida até o bairro do Jabaquara. Na Avenida Rangel Pestana, o réu teria entrado em luta corporal com o taxista, subtraindo a quantia em dinheiro que estava no bolso dele. O taxista disse que parou o veículo antes do destino final porque o réu anunciou o roubo. Disse que o acusado confessou no local a autoria dos dois roubos, alegando ser usuário de drogas. Explicou que os populares viram a vítima já caída no chão sangrando e o réu tentando fugir. Estas pessoas não foram levadas à delegacia. Referiu que o acusado apresentava escoriações leves. Declarou que encontrou em poder do acusado o dinheiro que pertencia ao taxista. O réu não chegou a conduzir o veículo da vítima. Não conhecia o acusado (gravação audiovisual, pp. 226/227).

Rafael Leão de Araújo Vale, policial militar, contou que estavam em patrulhamento quando foram acionados via COPOM a respeito de um roubo a veículo na Avenida Rangel Pestana. Dirigiram-se até o local e observaram alguns populares e o táxi parado. Verificaram que os populares estavam tentando deter o acusado. Assim, realizaram a detenção do réu e foram esclarecer os fatos, apurando que ele havia ingressado no táxi e tentado praticar o roubo contra o taxista. A vítima relatou à Polícia que réu contratou uma corrida de táxi até determinado destino e, naquele lugar, o acusado aplicou um golpe "gravata" no taxista e exigiu a entrega de dinheiro e da chave do veículo. Em seguida, os dois teriam entrado em luta corporal no interior do automóvel e o taxista ficou bastante machucado por conta das agressões. Esclareceu que o réu foi detido a poucos metros do táxi. Não se recorda se alguma quantia foi apreendida com o réu. Declarou que outros policiais reconheceram o acusado pelas vestimentas como o autor de um roubo ocorrido em uma farmácia naquela manhã. No local da detenção o réu admitiu informalmente a autoria do roubo ocorrido

na drogaria. Na delegacia, o funcionário da farmácia reconheceu o acusado. Recorda-se que o funcionário da farmácia contou que o réu fez alusão de estar armado. Informou que populares presenciaram o taxista sendo agredido pelo réu. Chegaram ao local quase no mesmo momento e não levaram nenhuma testemunha para prestar declarações na delegacia (gravação audiovisual, pp. 226/227).

Vê-se, assim, que ao contrário do que sustentou a Defesa, a prova amealhada é segura e dá suporte ao desate condenatório relativamente ao crime de roubo tentado praticado contra a vítima taxista.

Como aqui se apurou, o acusado abordou o ofendido contratando uma corrida de táxi e, ao chegarem ao destino, o réu segurou a vítima pelo pescoço e exigiu a entrega do dinheiro do taxista. Todavia, o ofendido puxou o seu banco para trás e reagiu fisicamente, travando luta corporal com o réu, ocasião em que o acusado acertou um isqueiro no rosto da vítima, cortando-a na altura dos olhos.

Logo após, populares se aproximaram e rapidamente acionaram a Polícia Militar. Os policiais militares lograram deter o acusado a poucos metros de distância do local onde o táxi estava parado.

Ao que se viu da prova colhida, na fase extrajudicial e também sob o crivo do contraditório, o réu foi reconhecido pela vítima e não se tem dúvida alguma a respeito da idoneidade e lisura desse reconhecimento.

Imediatamente após os fatos, e ainda no local, o acusado foi perseguido e detido pelos policiais militares, sendo prontamente reconhecido pela vítima, que naquela ocasião tinha as melhores condições de reconhecer aquele que havia acabado de assaltá-la.

Em Juízo, e mais uma vez, o ofendido apontou o acusado, que se fazia presente à audiência de instrução, realizada por videoconferência, confirmando que realmente identificou o autor da tentativa de subtração.

É certo, também, que não se tratou de luta corporal travada após mero desentendimento por ter o taxista se negado a continuar o percurso combinado ao verificar que estava se dirigindo a um ponto de venda de drogas. A prova revelou que a ação do réu foi motivada pela violenta subtração, pois além de não pagar a corrida ajustada, exigiu a entrega do dinheiro que estava em poder do taxista. Não se tratou de contenda motivada pela recusa do réu em pagar corrida incompleta, como alegou a Defesa.

Esclareceu o ofendido que, tão logo solicitada a corrida de táxi, explicou ao acusado que não levava passageiros até o conhecido ponto de venda de drogas no morro do Jabaquara, tendo o réu respondido que seu destino final era próximo à faculdade, de maneira que o taxista aceitou realizar a corrida.

Ressaltou o ofendido que, ao parar o veículo, o acusado falou que ficaria naquele local, razão pela qual encerrou a corrida e cobrou o valor a ser pago, momento em que o réu já agiu de forma alterada e iniciou as agressões físicas, exigindo a entrega de dinheiro.

Evidente, pois, que a pronta reação da vítima, que foi ferida pelo acusado em meio à luta travada para preservar seu patrimônio, evitou que o acusado se apossasse do numerário por ele exigido.

Não há contradições que retirem a credibilidade do contexto probatório, sendo necessário destacar que, como se sabe, crimes desta espécie são praticados por audaciosos agentes que, visando assegurar o sucesso de sua investida - sempre na clandestinidade - evitam qualquer alarde que possa despertar a atenção do público em geral.

Por tal razão, a palavra da vítima é de essencial importância, principalmente quando revestida de segurança, sinceridade e coerência.

É certo que, pelo coerente relato do ofendido, comprovado está que o réu praticou a tentativa de roubo narrada na denúncia, não se evidenciando qualquer intenção de prejudicar o acusado, pessoa que sequer conhecia.

Da lição de Mirabete se extrai que "...como se tem assinalado na doutrina e jurisprudência, as declarações do ofendido podem ser decisivas quando se trata de delitos que se cometem às ocultas (...). São também sumamente valiosas quando incidem sobre o proceder de desconhecidos, em que o único interesse do lesado é apontar os verdadeiros culpados e narrar-lhes a atuação e não acusar pessoas

inocentes. É o que ocorre, por exemplo, nos crimes de roubo..." (Júlio Fabbrini Mirabete, Processo Penal, 5ª ed., São Paulo, Atlas, 1996, pp. 288/9).

E, como já se decidiu:

"... Tratando-se de delito praticado na clandestinidade, como o roubo, é de dar-se especial relevância à palavra das vítimas, como elemento de prova, desde que não destoem do conjunto probatório e que não se encontrem, nos autos, indícios ou provas de que elas pretendam incriminar pessoas inocentes..." (TJSP; Apelação Criminal 0031860-73.2017.8.26.0050; Rel. Paulo Rossi; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento: 12/05/2020).

"... Nos crimes de roubo, muitas vezes praticados na clandestinidade, a palavra dos ofendidos assume especial importância, tanto para confirmar a materialidade e a autoria, como o emprego de violência ou de grave ameaça exercida contra pessoa, mediante emprego de arma de fogo..." (TJSP; Apelação Criminal 1500091-42.2018.8.26.0630; Rel. Grassi Neto; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento: 31/08/2020).

Patente e inegável o envolvimento do acusado nos fatos delituosos ora apurados e a prova oral - uníssona e coerente - bem indica que o acusado praticou o roubo tentado narrado na denúncia.

Registre-se que, apesar dos reclamos do réu, a negativa de autoria se vê desamparada de seguro elemento de prova, razão pela qual não merece crédito algum. Inaceitável a versão que o réu ofertou ao ser interrogado, pois quis fazer crer que tudo não passou de desavença relativa à contratação da corrida de táxi.

É inacreditável que a vítima elaborasse fantasiosa história, forjando a trama e falsamente imputando ao réu a exigência da entrega de bem, e tudo isso para indevidamente acusá-lo da prática de crime que ele não cometeu.

Despropositada, por absurda, essa situação, reafirmando-se que o relato do réu não é crível e não tem sustento em prova alguma.

Como acima exposto, demonstrada está a ocorrência da violência e grave ameaça, decorrentes da própria exigência da entrega de dinheiro, como também da luta corporal travada com a vítima.

Além disso, a prova revelou que se tratou de subtração tentada, que só não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do réu, pois é inequívoco que o acusado não teve posse do dinheiro cuja subtração almejava conquistar.

Por assim ser, em sendo firme e seguro o contexto probatório, notadamente a prova produzida sob o crivo do contraditório, há suporte indicando o desate condenatório relativamente à tentativa de roubo contra a vítima taxista.

De outro lado, e no que tange ao crime praticado contra a farmácia Drogasil, e ao que se viu do aqui apurado, não há prova plena e segura que realmente indique que é ele o autor da subtração narrada na petição inicial.

Segundo relataram os policiais militares, por ocasião do atendimento à ocorrência da tentativa de roubo contra a vítima taxista, colegas deles que estavam na viatura de apoio reconheceram o réu como autor do roubo ocorrido numa farmácia naquela manhã.

Assim, o funcionário da farmácia foi chamado à delegacia e realizou o reconhecimento pessoal do acusado, identificando-o como a pessoa que praticou a subtração (p. 10).

Todavia, em juízo, o funcionário da farmácia não reconheceu o acusado, que se fazia presente à audiência de instrução, apontando como autor do assalto um outro detento colocado ao lado do réu para reconhecimento, dizendo que o rapaz indicado se assemelha à pessoa que reconheceu na delegacia, pois ambos possuem tatuagens.

Quando interrogado, o réu negou a acusação, dizendo que nunca esteve no estabelecimento comercial e foi levado à delegacia em razão da prática de outro crime, vendo-se depois apontado como autor dos fatos ora apurados.

Outrossim, é certo que o acusado não foi preso por ocasião destes fatos e em poder dele nada relacionado a esta subtração foi encontrado.

Com efeito, não se tem a certeza necessária para reconhecimento de sua responsabilidade penal, já que o reconhecimento pessoal realizado em juízo com a observância das regras previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal não confirmou o reconhecimento pessoal efetuado pela autoridade policial.

Assim, e diante da fragilidade do contexto probatório, é certo que a negativa de autoria não pode ser descartada, pois a prova aqui reunida não é segura para a declaração da procedência do pedido inicial relativamente ao crime de roubo praticado contra a farmácia Drogasil.

Ao que se apurou, na fase extrajudicial, e mesmo que fosse possível, não se procedeu a reconhecimento pessoal conforme requisitos especificados no artigo 226 do Código de Processo Penal, contrariando os julgados recentes do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema.

Ainda que se possa entender que a não observância dos requisitos especificados no Código de Processo Penal não resulte, obrigatoriamente, na desconsideração completa da prova, essa deverá ser confrontada como um dos elementos probatórios do processo, cabendo sua análise em conjunto com as demais provas colhidas na instrução processual.

Não há como entender que tenha sido o réu efetivamente reconhecido como autor da subtração e, como já se destacou, não se tem notícia de que a res furtiva relativa ao roubo praticado na farmácia tenha sido encontrada em poder dele.

Nada mais se produziu, sendo forçoso reconhecer que a fragilidade do contexto probatório não permite o desfecho condenatório.

Frágil, pois, o contexto probatório, que não se prestou à elucidação adequada da autoria do fato delituoso que ao réu é imputado.

Nelson Hungria assinala que "a condenação criminal somente poderá surgir diante de uma certeza quanto à existência do fato punível, da autoria e da culpabilidade do acusado. Uma prova deficiente, incompleta ou contraditória, gera a dúvida e com ela a obrigatoriedade da absolvição, pois milita em favor do acionado criminalmente uma presunção relativa de inocência". (in, Da Prova no Processo Penal, Editora Saraiva, 1983, p. 46).

No mesmo sentido, Hélio Tornaghi leciona: "Nesse caso é que a máxima in dubio pro reo se aplica em toda sua força. Existem, no processo, elementos que levariam a considerar o réu culpado, mas há outros que permitem supô-lo inocente. Estabelece-se a dúvida no espírito do juiz e, nesse estado de incerteza, ele absolve".

(Instituições de Processo Penal. São Paulo: Saraiva, 1978. 2.^a ed. vol. 4. p. 393).

Desta forma, e ainda que, a princípio, tenha sido identificado e reconhecido pelo funcionário da farmácia, é de se reconhecer que as provas aqui colhidas não são concludentes e firmes para ensejar decreto condenatório quanto ao crime de roubo praticado contra a Drogasil.

Procede, em parte, o pedido inicial.

Passo à individualização da pena.

O acusado é primário (certidão de p. 211).

Registre-se que não é caso de ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea, como requereu a Defesa, pois o acusado apenas admitiu que estava no interior do táxi e travou luta corporal com a vítima, negando a prática de conduta relacionada à subtração de coisa alheia móvel.

Ao que se verifica de suas declarações, o réu quis dar ao fato colorido penal diverso daquele retratado na prova aqui reunida.

Com efeito, "aquele que confessa o feito em parte, ocultando dinâmica essencial à configuração do tipo penal, na verdade não confessou, não foi sincero e não demonstrou arrependimento, mas apenas visou justificar seu ato ou fugir às consequências do mesmo, descaracterizando o tipo penal ou reduzindo a gravidade do delito a ele imputado. Em resumo, não se reconhece a confissão incompleta, pois se trata de confissão de fato diverso da condenação." (TJSP. Apelação n.º 0004497-94.2014.8.26.0510. Rel. Lauro Mens de Mello; Comarca: Rio Claro; Órgão julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 03/05/2017).

E, como já decidiu o Supremo Tribunal Federal:

"HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA NÃO CONFIGURADA. CONFISSÃO DE FATO DIVERSO DO DA CONDENAÇÃO. PRISÃO EM FLAGRANTE. IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DO ART. 65, III, D, DO CÓDIGO PENAL. INVIABILIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO NA VIA DO HABEAS CORPUS PARA AFASTAR O QUE DECIDO NA AÇÃO PENAL. ORDEM DENEGADA. Confissão de fato diverso, não comprovado durante a instrução criminal, impossibilita a incidência da atenuante genérica de

confissão espontânea, prevista no art. 65, III, d, do Código Penal. Precedente" (STF HC 108148/MS - Rel. Min. Ricardo Lewandowski j. 07.06.2011).

Desta forma, incabível o reconhecimento da atenuante em questão, até porque a versão apresentada pelo réu não foi utilizada para a formação do convencimento, não sendo caso de aplicação do enunciado da Súmula 545 do Superior Tribunal de Justiça. Indiscutível, ademais, que as circunstâncias e consequências do crime são desfavoráveis, uma vez que a vítima teve o rosto lesionado em razão da agressão física, necessitando receber atendimento médico, com sutura do corte e aplicação de pontos no rosto.

Esse proceder revela que o crime foi cometido com violência exacerbada e desmedida, superado, assim, o comportamento criminoso esperado e hábil a caracterizar a infração penal, ainda que se reconheça que a violência física integre o tipo penal. É certo também que o ofendido perdeu o restante do dia de trabalho como taxista, sendo evidente o prejuízo patrimonial sofrido por ele.

Assim, levando em conta os critérios previstos no artigo 59 do Código Penal, em especial em razão das circunstâncias e consequências do crime, aumento a pena-base em 1/4 (um quarto), fixando-a em 5 (cinco) anos de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Ademais, presente a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea c, do Código Penal, representada pela dissimulação ou outro recurso que dificultou a defesa da vítima, pois o acusado ludibriou o ofendido, aproveitando-se de sua boa-fé, fazendo-o acreditar que transportaria um passageiro regular.

Destaque-se que essa ardisa atitude não é elementar do tipo penal e, portanto, não caracteriza bis in idem.

Não fosse isso, o acusado atacou a vítima pelas costas, com um golpe "gravata", enquanto o taxista estava acomodado no banco do motorista.

Desta forma, nesta fase, aumento a pena em 1/6 (um sexto), fixando-a em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e 14 (quatorze) dias-multa.

Tratando-se de crime tentado, e à vista do iter criminis percorrido pelo acusado, que não obteve posse da res furtiva, apesar da agressão física perpetrada contra o ofendido, diminuo a pena em 1/2 (metade), fixando-a em 2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão, e 7 (sete) dias-multa, pena essa que torno definitiva, por não haver circunstância que a modifique.

Não obstante o quantum da pena aplicada e ainda que primário, iniciará o cumprimento da pena em regime fechado, por conta das particularidades do caso, já apontadas na motivação relativa às desfavoráveis circunstâncias e consequências do crime e ao modus operandi empregado pelo réu, pois ludibriou o ofendido, fazendo-o acreditar que transportaria um passageiro, sendo forçoso reconhecer que a fixação de regime diverso retiraria a eficácia da pena, incentivando a prática deste tipo de delito.

Não se poderia deixar de levar em conta que crimes como o ora analisado afligem a sociedade, revelam despreparo para o convívio social e indicam potencial periculosidade de seu autor.

Note-se que o crime foi praticado em plena luz do dia e o réu o fez mediante emprego de exacerbada violência física, agarrando a vítima por trás pelo pescoço (golpe de "gravata") e acertando-a no rosto com um isqueiro, fazendo-a sangrar e necessitar de atendimento médico.

Não se trata, portanto, de situação em que simples e abstrata gravidade do delito é utilizada como fundamentação para a imposição de regime prisional mais gravoso do que o permitido para a sanção aplicada, uma vez que essa escolha se fundamenta nas circunstâncias do caso concreto.

Desta forma, e como já se disse, iniciará o réu o cumprimento da pena em regime fechado.

Ressalte-se que inadmissível o reconhecimento da detração penal prevista no parágrafo 2º, do artigo 387, do Código de Processo Penal, aplicando-se regime prisional mais brando para o início de cumprimento da reprimenda, pois tal qual determina a Lei n.º 12.736/2012, reconhece-se o direito à progressão para um regime mais benéfico, desde que se preenchidas as condições preceituadas nos artigos 113 e 114 da Lei n.º 7.210/84 (aceitação de seu programa e das condições impostas pelo Juiz; necessidade de estar trabalhando ou comprovar a possibilidade de fazê-lo

imediatamente e apresentar, pelos seus antecedentes ou pelo resultado dos exames a que foi submetido, fundados indícios de que irá ajustar-se, com autodisciplina e senso de responsabilidade, ao novo regime), tudo a ser comprovado perante o Juízo da Execução.

Cabe observar, ademais, que a não aplicação da detração de que trata o artigo 387, parágrafo 2º, do Código de Processo Penal também se justifica pelo fato de o regime inicial para cumprimento da pena privativa de liberdade de reclusão não ter sido fixado com base na quantidade da pena, mas tendo em conta as circunstâncias do caso.

Não havendo informações concretas acerca da situação econômica do acusado, fixo o dia-multa no mínimo legal.

Tratando-se de crime de roubo cometido com violência contra a pessoa, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, à vista do disposto no artigo 44 do Código Penal.

Incabível a concessão do sursis, seja pelo quantum de pena aplicada, seja porque as circunstâncias judiciais não são favoráveis ao acusado, nos termos do artigo 77 do Código Penal.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE EM PARTE o pedido inicial para:

- a) absolver GABRIEL OLIVEIRA MENDES RIBEIRO DE BARROS, qualificado nos autos, da acusação que lhe é feita como incurso nas sanções previstas no artigo 157, caput, do Código Penal, e o faço com fundamento no disposto no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal;
- b) condenar GABRIEL OLIVEIRA MENDES RIBEIRO DE BARROS, qualificado nos autos, à pena de 2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão, a serem cumpridos inicialmente em regime fechado, e 7 (sete) dias-multa, calculados ao valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo vigente à época dos fatos, por incurso nas sanções previstas no artigo 157, caput, c.c. o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Nos termos do disposto no artigo 4º, parágrafo 9º, da Lei Estadual nº 11.608/03, arcará o réu com custas processuais correspondentes a 100 (cem) UFESP'S, calculadas ao valor vigente à época do pagamento.

Note-se que, apesar da declaração de p. 71, por meios próprios, pôde o réu constituir defensor de sua confiança. Ainda, é certo que ele não tem filhos e vive com seus pais e esposa que trabalham e auferem renda, como ele próprio declarou ao juízo. Desta maneira, por evidente, não pode ser considerado pobre na acepção jurídica do termo e nem demonstra fazer jus à concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

O acusado viu convertida a prisão em flagrante em prisão preventiva. É certo que o fato aqui apurado desassossega a sociedade, compromete a paz social e desequilibra a ordem pública. Trata-se de crime contra o patrimônio, que repugna e aflige a sociedade ordeira, que se vê perplexa e assustada com a ousadia dos assaltantes, destacando-se aqui que o ofendido foi rendido no interior do automotor, pois contratado para realizar a corrida solicitada pelo acusado que se apresentou no ponto de táxi.

Desta forma, a prisão por sentença condenatória recorrível se revela necessária, seja para assegurar a efetiva aplicação da lei penal, bem como para resguardo da ordem e paz públicas.

Lembre-se, ainda, que o réu se vê envolvido na apuração de grave delito cometido a plena luz do dia e com exacerbada violência física contra a vítima.

Assim, é forçoso reconhecer que essa situação não revela que seja ele pessoa de boa conduta social, mantendo vida desregrada e fazendo da criminalidade e do ataque ao patrimônio alheio seu meio de vida.

Por final, necessário registrar que as medidas elencadas nos artigos 319 e 320 do Código de Processo Penal não se mostram adequadas para acautelar o procedimento, agora julgado nesta Instância, sendo forçoso reconhecer que, em liberdade, o acusado poderá por em risco a aplicação da lei penal, pois condenado a cumprir pena em gravoso regime.

Assim, recomende-se o réu na prisão em que se encontra.

Deixo de arbitrar valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração,

pleito formulado pelo Ministério Público a p. 90, pois nenhum bem foi subtraído da vítima e não há parâmetros para a fixação de valor mínimo de reparação de danos materiais ou morais, uma vez que não se produziu prova a esse respeito na instrução criminal.

Anote-se a condenação definitiva no Sistema Informatizado Oficial, com as devidas comunicações ao IIRGD, nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça.

P.I.C.

Santos, 19 de dezembro de 2022.

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Silvana Amneris Rôlo Pereira Borges

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA